

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7178/2562

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
เด็กชาย น. โดยนางสาว ร. ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย ป.

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม)

คำว่า "อนาจาร" มีความหมายว่า การกระทำที่ไม่สมควรทางเพศ ซึ่งรวมถึงการแตะต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควร ส่วนการกระทำชำเราหมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น การกระทำชำเราจึงรวมถึงการกระทำอนาจารอยู่ในตัว เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยชู้บังคับให้ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีอายุ 9 ปีเศษนอนลงกับพื้น อ้าขาและใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่ 1 การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยชู้เชิญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม) และฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 279, 283 ทวิ, 317

จำเลยให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา เด็กชาย น. ผู้เสียหายที่ 1 โดยนางสาว ร. ผู้เสียหายที่ 2 มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายด้านร่างกาย กับการเสียชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

จำเลยไม่ให้การในคดีส่วนแพ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), 279 วรรคสอง (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 20 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 ฐานกระทำความชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จำคุก 10 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร จำคุก 4 ปี รวมสอง กระทั่ง จำคุก 14 ปี ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดฐานกระทำความชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จำคุก 7 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี ลดโทษกระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 5 ปี 12 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 279 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำ ของจำเลยเป็นความผิดฐานกระทำความอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน ได้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า คำว่า "อนาจาร" มีความหมายว่า การก ระทำที่ไม่สมควรทางเพศ ซึ่งรวมถึงการแตะต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควร ส่วนการกระทำความชำเราหมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการ ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น การกระทำความชำเราจึงรวมถึงการกระทำความอนาจารอยู่ในตัว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความ

ว่า จำเลยขู่บังคับให้ผู้เสียหายที่ 1 นอนลงกับพื้น อ้าขา และใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในทวารหนักของผู้เสียหายที่ 1 การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง และฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 มาตรา 5 และมาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 และมาตรา 279 และให้ใช้ความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม) ด้วย ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ กับฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น

จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 สำหรับโทษและนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 9

(สันติ วงศ์รัตนานนท์-นิรัตน์ จันทพัฒน์-สมเกียรติ ตั้งสกุล)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายปยุตต์ บุนนาค

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นางนิจรินทร์ องค์กรพิสุทธิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 3590/2561

ต้น

หมายเหตุ